

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0010904-61.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **DANILO LIMA DA SILVA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Edison Tetsuzo Namba****VISTOS**

DANILO LIMA DA SILVA (18 anos de idade) e **ANTONIO RODRIGUES** (21 anos de idade), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, “caput”, art. 35, “caput” e art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque em 11.8.2016, por volta das 22 horas e 20 minutos, na Avenida Presidente Wilson, 2000, Ipiranga, São Paulo, associaram-se aos adolescentes *Vitor Hugo Silva de Lima* e *Everson de Sousa e Silva*, a fim de praticar reiteradamente a prática de tráfico de drogas, pois traziam consigo e guardavam, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal, 78 papелotes contendo tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 111,8 g, e 266 papелotes contendo cocaína com peso líquido de 194,6 g.

Segundo o apurado, Policiais Civis em atendimento à ordem de serviço ao combate do tráfico de drogas, realizavam campana no local dos fatos, quando observaram o adolescente Everson nos fundos da “Favela PW” exercendo a função de “Olheiro”, este acabou sendo abordado e informou que recebia a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais) por turno. Em seguida, os Policiais seguiram em direção ao ponto de tráfico onde surpreenderam o outro adolescente e os réus. Em revista pessoal, na posse de Vitor foi encontrado um pacote de dinheiro envolto com uma fita adesiva, contendo a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como três cadernetas com anotações da contabilidade do tráfico, sendo que uma delas continha um desenho do numeral “1553”, indicador da organização PCC, com Danilo foi localizado um saco de pano de cor preta, contendo as drogas supra descritas, e com o Antônio foi encontrada a quantia de R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Foi determinada a notificação dos réus em 19.12.2016 (fls. 168/169), sendo ela efetivada, defesas prévias foram oferecidas, recebimento da peça acusatória em 9.2.2017, com instrução, interrogatórios e debates.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O Ministério Público pediu a condenação dos réus, pois comprovados os fatos atribuídos pelos réus.

Os acusados, por ilustre Defesa, pleitearam a absolvição, pela insuficiência de provas, alternadamente, Danilo quer a pena mínima, incidência da menoridade e regime inicial semiaberto, sem haver associação e uso da diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 206/211).

É o relatório.

DECIDO

A ação é parcialmente procedente.

A *materialidade do delito* foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 8/25, boletim de ocorrência de fls. 28/34, auto de exibição e apreensão de fls. 35/37, laudo de constatação de fls. 38/40 e laudo de fls. 182/184, cocaína e maconha foram apreendidas.

A *autoria* é atribuível aos réus quanto tráfico, com participação de adolescentes.

No distrito, ficaram em silêncio, fls. 24/25, respaldado em norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. **Apel. nº 1.245.929/0**, julgado em 19.3.2001, 11ª Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.

Fernando, policial civil, prendeu os réus. Estavam com dois adolescentes, um perto e outro olheiro. Os quatro admitiram a traficância. Local ponto de tráfico. Foi até lá por Ordem de Serviço. Danilo, réu, estava com droga (várias porções – mais de 200 – cocaína e maconha).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Dinheiro apreendido, parcela com *Victor Hugo* (menor), outra com Antonio. Falaram que agiam juntos. Os moradores estavam vendo, só esposa de *Victor Hugo* foi lá para saber destino. Estavam num beco no interior da comunidade. Dois cadernos de anotações foram recolhidos (salvo engano, quem fazia anotação era *Victor Hugo*, com R\$ 6.000,00). Danilo foi levado para averiguação, não foi preso ou detido. Estava com Aparecido e Oswaldo, além de Eduardo. Marcelo Soares é um dos usuários que compravam droga. Adquiria drogas dos réus. Em primeiro lugar, abordaram olheiro. Tinham noção para agir. Deu voz de prisão, com Pereira, com os réus. Danilo não falou ser usuário de droga.

Aparecido, policial civil, prendeu os réus. Estavam com dois adolescentes, um perto e outro olheiro. Os quatro admitiram a traficância. Local ponto de tráfico. Foi até lá por Ordem de Serviço e flagrantes no local. Danilo, réu, estava com droga (várias porções – mais de 200 – cocaína e maconha). Dinheiro apreendido, parcela com *Victor Hugo* (menor), outra com Antonio. Falaram que agiam juntos. Ninguém interveio. Estavam num beco no interior da comunidade. Dois cadernos de anotações foram recolhidos (salvo engano, quem fazia anotação era *Victor Hugo*, com R\$ 6.000,00). Danilo foi levado para averiguação, não foi preso ou detido. Estava com Fernando e Oswaldo, além de Eduardo. Marcelo Soares é um dos usuários que compravam droga. Adquiria drogas dos réus. Em primeiro lugar, abordaram olheiro. Tinham noção para agir. Deu voz de prisão, com Fernando, com os réus. Os quatro não falaram ser usuário. Menor *Victor* gerente. Os outros três, Antonio e menores não foram presos antes.

Oswaldo, policial civil, entrou pela frente. Quem prendeu foram seus parceiros. Prendeu Marcelo, este disse que comprou droga de Danilo e Antonio. Estavam com dois adolescentes, um perto e outro olheiro. Os quatro admitiram a traficância. Local ponto de tráfico. Foi até lá por Ordem de Serviço e flagrantes no local. Danilo, réu, estava com droga (várias porções – mais de 200 – cocaína e maconha). Dinheiro apreendido, parcela com *Victor Hugo* (menor), outra com Antonio (R\$ 200,00 ou R\$ 300,00). Não lembra de ação conjunta. Ninguém interveio. Estavam num beco no interior da comunidade. Dois cadernos de anotações foram recolhidos (salvo engano, quem fazia anotação era *Victor Hugo*, com R\$ 6.000,00) – negociação de droga, contabilidade deles. Danilo foi levado para averiguação, não foi preso ou detido. Estava com Fernando e Aparecido. Em primeiro lugar, abordaram olheiro, menor. Tinham noção para agir. Os quatro não falaram ser usuário. Menor *Victor* gerente. *Victor Hugo* apreendido antes, seis meses. Entrou na favela, os dois outros policiais entraram primeiro. Não viu prisão de Danilo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
Antonio.

Os policiais civis incriminam os réus de maneira ampla e irrestrita, sem qualquer divergência entre eles. Os acusados agiram com os menores para o tráfico de droga, em quantidade razoável, envolvendo dinheiro.

Não há indício de que desejassem prejudicar, gratuitamente, os réus e os menores. Se agiram, foi em razão da existência do crime permanente de comércio espúrio de droga. Deveriam intervir, sob pena de praticarem crime de prevaricação.

Deve prevalecer, pois, a presunção de legitimidade do exercício de suas funções, que, aliás, foram determinadas por ordem de serviço.

Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. **Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus nº 74.251/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e **Habeas Corpus nº 73.518/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. **Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus nº 98766/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; **Habeas Corpus nº 130537/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; **Habeas Corpus nº 115510/SP**, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; **Habeas Corpus nº 38489/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e **Habeas Corpus nº 28417/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação nº 990.09.025057-7**, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.150746-6**, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.056197-1**, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 993.04.076694-0 e 990.09.047692-3**, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Lopes da Silva e Des. Cardoso Perpétuo, J. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.200330-5**, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 990.09.174019-5**, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Passos, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 993.08.007218-3**, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. David Haddad, Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 990.09.173798-4 e 990.09.184274-5**, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, na sequência, os Des. Penteado Navarro e Des. Galvão Bruno, Julg. 12.11.2009 e 29.10.2009; **Apelação nº 990.09.130107-8**, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203175-9**, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sydney de Oliveira Jr., Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 993.08.044297-5 e 993.05.075368-9**, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Machado de Andrade e Des. José Raul Gavião de Almeida, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203944-0**, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 990.08.051988-3 e 993.05.002085-1**, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Augusto Siqueira e Des. William Campos, Julg. em 17.11.2009 e 24.11.2009; **Apelação nº 990.09.006709-8**, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; **Apelação nº 990.08.123484-0**, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009; **Apelação nº 990.09.219512-3**, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Julg. 30.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

Interrogado, o **réu Antonio** declarou ter 22 anos de idade. Na época da prisão estava com 21 anos de idade. É primário. É inocente. Conhece apenas Vítor, menor. No local que mora, ponto de venda de droga. Já viu ele comercializar. Estava com sua mulher quando preso. Estava com R\$ 20,00, não tinha droga. Não tinha anotação de tráfico. Passou o beco, para levar sua mulher que passou mal, sendo detido por policial. Antes, um armado correu, seguiu-se o policial. Quando o prenderam, levado, tinha muita droga no chão. Não viu dinheiro e anotações. Na delegacia, soube das imputações. Não conhecia os policiais, está preso há 3 meses, por isso não está satisfeito. Sua mulher não trabalha. Já foi levado à delegacia, uma vez, por polícia militar. Voltava do trabalho na ocasião.

Danilo asseverou ter 18 anos de idade. É primário. É inocente. Não conhece os outros três supostos participantes. Foi preso quando só. Pegou maconha na favela, 2. Não tinha dinheiro. É usuário há 5 anos. Mora nas imediações. Levaram para dentro da favela, assumiria as drogas, era traficante, colocou na viatura e levado ao distrito. Na viatura viu o corréu e os dois menores. Iria para casa. 2 meses que comprava droga no local. Os policiais civis pegaram-no tempos atrás, na mesma rua, dito que era traficante, levado à delegacia e liberado. Desconhece Marcelo Soares.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não tem ideia do motivo as acusações. Não tinha caderno com anotações.

O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O *interrogatório* é tanto *meio de prova* como de *defesa*, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de *meio de defesa* e de *prova*, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (*Curso completo de processo penal*. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).

As versões são frágeis, inverossímeis e dissociadas do conjunto probatório.

Embora haja menção do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, não há em verdade uma associação, mesmo eventual, eles estavam juntos momentaneamente, ademais, já existe a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da mesma lei, quanto aos adolescentes.

O lugar era conhecido como ponto de tráfico, havia ordem de serviço cumprida pelos policiais, existindo quantidade não desprezível de droga e valores altos. Tudo a mostrar a existência de comércio espúrio de drogas.

Por derradeiro, cadernos com contabilidade do tráfico foram apreendidos e a letra do réu **Danilo** constava lá (fls. 178/181).

Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na questão técnica discutida em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (*Instituições de direito processual civil*. V. III. Tradução da 2ª ed. por Paolo Capitanio. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).

Em suma, os silêncios extrajudiciais, negativas infundadas, depoimentos policiais e apreensão provam o tráfico, com maior e menores, realizado pelos acusados.

Doso as penas.

1ª fase

Considerando a diretriz do art. 59 do Código Penal, a primariedade e antecedentes dos réus, o resultado e consequências do crime, normais se comparados a casos análogos, o grau de culpa, fixo as penas-base no mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, para cada um.

2ª fase

“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 – STJ (...))” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a menoridade não influi na pena de **Danilo**.

Não há outras atenuantes ou agravantes.

3ª fase

Os réus, conforme dito, são primários, além disso, de bons antecedentes, dedicam-se às atividades criminosas e integram organização criminosa, dessa maneira, por não ser desprezível a quantidade de droga encontrada (344 unidades de tráfico), a pena permanece no mesmo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

"quantum".

A causa de aumento incide, eles estavam com menores, logo, aumento cada pena de 1/6, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

Não há causas de diminuição e outras de aumento.

Penas finais

As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam.

Regime

O regime das penas privativas da liberdade deve ser inicial fechado.

Segundo a nova redação do art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/1990, em conformidade à Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007: "A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado".

Os acusados praticaram delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em escala mundial, pelas conseqüências danosas que causa à sociedade, primordialmente quando a quantidade não é desprezível.

Cabe invocar ensinamento do STF: "***A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.***" (HC nº 70.289-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).

Ora, é de pronta inteligência que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete: “A pena de prisão teve sua origem nos mosteiros da Idade Média, “como punição imposta aos monges ou clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio, à meditação e se arrependessem da falta cometida, reconciliando-se assim com Deus” (Manoel Pedro Pimentel. *O crime e a pena na atualidade*. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 134). Essa idéia inspirou a construção da primeira prisão destinada ao recolhimento de criminosos, a *House of Correction*, construída em Londres em 1550 e 1552, difundindo-se de modo marcante no Século XVIII” (*Manual de direito penal*. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 1986, p. 246-247).

Na mesma obra, lembra: “Se do ponto de vista educativo e recuperatório a pena de prisão apresenta tais aspectos negativos, não se pode, entretanto, questionar que continua ela a ser o único recurso aplicável para os delinquentes de alta periculosidade. Mesmo Foucault, acerbo crítico do sistema prisional, reconhece que nessa hipótese não há possibilidade de mudança, sendo a pena de prisão detestável solução de que não se pode abrir mão. E Manoel Pedro Pimentel lucidamente afirma: “A prisão precisa ser mantida, para servir como recolhimento inicial dos condenados que não tenham condições de serem tratados em liberdade” (Ob. cit., p. 185-186). A prisão, deve-se reconhecer é insuprimível, quer como instrução de repressão, quer como defesa social” (p. 249).

Se, mais além e com efetividade, se almeja observar o princípio de individualização das penas, é preciso, como fez ver Karl Mannheim, que o juiz proceda “em relação ao delinquente individual como o legislador faz em relação aos delinquentes em abstrato” (*Criminologia Comparada*, tradução portuguesa de J. F. Faria Costa e M. Costa Andrade, ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984, vol I, p. 216).

O que deve ser levado em conta para a fixação do regime não é o crime em sua dimensão abstrata – vale dizer, a gravidade hipotética de um delito – e sequer exclusivamente em sua posição concreta pretérita, até porque a só gravidade jurídica da pena de um crime “carece freqüentemente de significação desfavorável para o prognóstico” (Middendorff, remetendo-se a lições de Mannheim, Bockelmanne e dos Glueck. *Teoria y Práctica de la Prognosis Criminal*. Madrid, Ed. Espasa – Calpe, 1970, 128).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Jescheck diz que para dosar a pena deve-se levar em conta “crescente aumento de determinadas classes de delito em algum setor concreto (prevenção geral)” (*Tratado de derecho penal*. Tradução castelhana de Mir Puig e Muñoz Conde, Ed. Bosch, Barcelona, 1981, vol II, parágrafo 82, III, n. 2.).

A benevolência infundada – a que se referiu graficamente Jescheck (Op. cit., vol I, parágrafo 1, I, n. 2) -, ou, na dura expressão de Exner “as fraquezas do juiz, que deixam indefesa a sociedade” (*apud* Middendorff. Op. cit., p. 168), terminam por adquirir um influxo propiciador não só da recidiva do condenado – frustrando a meta de prevenção específica – mas também do contágio hierárquico – reduzindo a eficácia da prevenção genérica.

Dessa forma, repreende-se as condutas dos réus, previne-se que não mais a cometam, tampouco outros crimes, e procure se ressocializar.

“Cícero, no “De Officiis”, I, 58, dizia que o homem não pode ficar sozinho e, permanentemente procura companhia para falar e ouvir, ensinar e aprender, mesmo que, com uma espécie de varinha mágica, *quasi vírgula divina*, pudesse obter tudo o que quisesse, o homem é sócio do homem. Platão, na “República”, II, 369, diz que a vida urbana é exposta como causada pela necessidade. Aristóteles, “Política”, I, ao contrário, salienta que “animal político”, *politikon zoon*, está para significar que o modo ideal de existência humana consiste em viver na *polis*, ou cidade-estado” (Antonio Junqueira de Azevedo. “Ciência do Direito, Negócio Jurídico e Ideologia”. *Estudos em homenagem ao professor Silvio Rodrigues*. São Paulo, Editora Saraiva, 1989, p. 18-19.)

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena.

Pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2º, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6ª T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Além disso, o tráfico é equiparado ao delito hediondo, assim, incidia o então art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, que previa o regime integral fechado, dispositivo constitucional, segundo parcela considerável da jurisprudência (apenas para exemplificar vide RT 735/581, 724/577; RSTJ 76/268; JTJ 179/304; dentre outros julgados).

Dessa maneira, não é apropriado substituir as penas privativas da liberdade por penas restritivas de direitos. Em caso contrário, ficariam com sentimento de impunidade em seu espírito, dificultando a apreensão da extensão da atitude ilícita.

Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.

Valor do dia-multa

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela precariedade econômica dos réus (art. 43, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e art. 49, parágrafo 1º, do Código Penal), com atualização prevista no art. 49, parágrafo 2º, do Código Penal (***"A atualização da pena de multa assegura a permanente manutenção do montante, sem qualquer alteração do mesmo, até o efetivo pagamento, sob pena de, dada as intempéries que assolam o nosso País, o exigível nada representar"*** (RT 683/327) e ***"A atualização monetária da pena de multa é a grande inovação da Reforma Penal de 1984 e não pode ser abolida por decretos-lei que visam a organizar a economia do País. O parágrafo 2º do art. 49 do CP, que sobre ela dispõe, tem caráter de norma penal em branco. A mudança dos índices de atualização monetária (norma complementar) em nada altera a essência da lei"*** (RT 636/312).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, CONDENANDO os réus **DANILO LIMA DA SILVA** (18 anos de idade), qualificado nos autos, à pena de **cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, com regime inicial fechado**, e pagamento de **quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa**, como incurso no **art. 33, “caput”, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal** e **ANTONIO RODRIGUES** (21 anos de idade), qualificado nos autos, à pena de **cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, com regime inicial fechado**, e pagamento de **quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa**, como incurso no **art. 33, “caput”, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006**.

Os acusados não poderão recorrer em liberdade, pois fixados os regimes iniciais fechados, ficaram presos durante a instrução e suas periculosidades não são desprezíveis. Nunca é demais lembrar que “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência” (Súmula nº 9 do ESTJ). ***“O STF tem decidido que o disposto no item LVII, do art. 5º da CF de 1988, ao dizer que 'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória', não revogou os dispositivos do CPP que prevêm a prisão processual”*** (RJTJERGS 148/15). ***“O art. 5º, LVII, da Constituição não alterou o art. 594 do CPP, segundo entendimento consagrado na Súmula 9 do STJ”*** (RT 686/391). No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7. Além disso, vide art. 59 da Lei nº 11.343/2006.

Recomendem-se na prisão.

Nomes no rol, oportunamente.

Não há prejuízo mensurável do crime, logo, descabe a fixação de algum valor para reparação de dano, conforme o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008.

Decreto a perda dos valores encontrados com os réus, 3 telefones celulares (fls. 35/36) e da quantia de R\$ 6.216,00 (fls. 36), acaso não tenha sido determinado no Juízo da Infância e Juventude, no que tange ao valor encontrado com Victor Hugo Silva de Lima, com

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fulcro no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal promulgada em 5.10.88, e art. 63 e parágrafos 1º ao 4º da Lei nº 11.343/2006, pois produtos do crime.

Oficie-se para destruição das drogas, da sacola e das três cadernetas se não estiverem instruindo laudo.

Custas de 100 UFESPs.

P. R. I. e C., oportunamente, arquivem-se.

São Paulo, 1º de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**